

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

14325/2558

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นายวีรบูรณ์ บุรินทรานนท์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 82, มาตรา 90

แม้กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2552 อันมีผลใช้บังคับนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป แสดงว่าก่อนหน้าวันที่ 29 กันยายน 2552 นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ แต่ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 บทเฉพาะกาล มาตรา 90 บัญญัติว่า "ผู้ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร์หรือร้านวีดิทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเมื่อยื่นคำขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากนายทะเบียน" ดังนี้ จำเลยประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ จำเลยต้องยื่นคำขอใบอนุญาตจากนายทะเบียน มิฉะนั้นย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 53 วรรคหนึ่ง จำเลยจะอ้างว่าประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นเวลาก่อนหน้าที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวประกาศใช้ จำเลยย่อมไม่อาจได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามกฎหมายจากนายทะเบียนหาได้ไม่

จำเลยเปิดร้านเกมและบริการอินเทอร์เน็ตในระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นวัสดุที่มีการบันทึกภาพหรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนำมาฉายให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว

ได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเกมการเล่นโดยทำเป็นธุรกิจและรับประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต โจทก์มีคำขอให้ลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2552 เป็นคำขอโดยอาศัยบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 82 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 53 วรรคหนึ่ง...ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่" ความผิดฐานจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นความผิดจากการตั้งหรือประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตในแต่ละครั้งแต่ละคราว เมื่อหยุดประกอบกิจการแล้ว ก็ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ตามคำบรรยายฟ้องโจทก์ระบุว่าจำเลย กระทำความผิดเฉพาะวันที่ 4 เมษายน 2552 เวลาใกล้ค่ำก่อนเที่ยง ในคำบรรยายฟ้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่าจำเลยมีการกระทำความผิดต่อเนื่องออกไปอีก หลังเกิดเหตุจำเลยไม่ได้ประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ตามฟ้องต่อไป เมื่อไม่มีข้อเท็จจริงใดให้โจทก์ยืนยันในคำฟ้องได้ว่าจำเลยยังคงกระทำความผิดต่อเนื่องออกไปอีก จึงไม่อาจลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 4, 53, 82 และปรับรายวันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2552

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง, 82 ปรับ 100,000 บาท และปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2552 ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 หากจะต้องกักขังแทนค่าปรับ ให้กักขังเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามฟ้องโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ชั้นสอบสวนจำเลยยอมรับว่าไม่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน คงโต้เถียงเพียงว่ารับทราบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่า ภายใน 60 วัน หลังจากเริ่มประกอบกิจการ สามารถประกอบกิจการได้โดยไม่มีใบอนุญาตเท่านั้น ส่อไปในทางยอมรับว่าร้านของจำเลยเปิดให้บริการเล่นเกมออนไลน์ด้วย ชั้นพิพากษาคดี จำเลยก็มีได้ถามค้านพยานโจทก์ผู้จับกุมไว้ จำเลยเพ่งหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาอ้างในภายหลังจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ที่จำเลยอ้างว่า ขณะจำเลยเปิดร้านในวันที่ 1 เมษายน 2552 ยังไม่มีกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์

พ.ศ.2551 นั้น เห็นว่า แม้กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้าน
นันทนาการ พ.ศ.2552 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2552
อันมีผลใช้บังคับนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป แสดงว่าก่อนหน้าวันที่ 29 กันยายน
2552 นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านนันทนาการตามกฎหมาย
กระทรวงฉบับดังกล่าวได้ แต่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
บทเฉพาะกาล มาตรา 90 บัญญัติว่า "ผู้ใดประกอบกิจการโรงภาพยนตร์หรือร้านวิดีโอ
ทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้ต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ
เมื่อยื่นคำขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบ
อนุญาตจากนายทะเบียน" ดังนี้ จำเลยประกอบกิจการร้านนันทนาการ จำเลยต้องยื่น
คำขอใบอนุญาตจากนายทะเบียน มิฉะนั้นย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 53 วรรคหนึ่ง
จำเลยจะอ้างว่าประกอบกิจการร้านนันทนาการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นเวลาก่อน
วันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวประกาศใช้ จำเลยย่อมไม่อาจได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการร้านนันทนาการตามกฎหมายจากนายทะเบียนหาได้ไม่ นอกจากพยาน
หลักฐานโจทก์ดังกล่าวแล้ว โจทก์ยังมีนายประดิษฐ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ
การพิเศษ เป็นพยานยืนยันว่า จำเลยมิได้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนการขออนุญาต
ประกอบกิจการร้านนันทนาการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
ด้วย ข้ออ้างของจำเลยจึงรับฟังไม่ได้ ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์ที่น่าสืบมานี้น่าหนัก
มันคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยเปิดร้านเกมและบริการอินเทอร์เน็ต
ในระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นวัสดุที่มีการบันทึกภาพหรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนำ
มาฉายให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเกมการเล่นโดย
ทำเป็นธุรกิจและรับประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านนันทนาการโดยทำ

เป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ที่โจทก์มีคำขอให้ลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม
2552 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2552 เป็นคำขอโดยอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 82 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 53
วรรคหนึ่ง...ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่" เห็นว่า ความผิดฐานจัดตั้งหรือ
ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้อ
รับใบอนุญาต เป็นความผิดจากการตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ โดยไม่ได้อ
รับใบอนุญาตในแต่ละครั้งแต่ละคราว เมื่อหยุดประกอบกิจการแล้ว ก็ไม่เป็นความผิดอีก
ต่อไป ตามคำบรรยายฟ้องโจทก์ระบุชัดว่าจำเลยกระทำความผิดเฉพาะวันที่ 4
เมษายน 2552 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง ในคำบรรยายฟ้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่า
จำเลยมีการกระทำความผิดต่อเนื่องออกไปอีก และโดยสภาพพฤติการณ์ในคดีนี้เชื่อ
ว่าหลังเกิดเหตุจำเลยไม่ได้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามฟ้องต่อไป เมื่อไม่มีข้อ
เท็จจริงใดให้โจทก์ยืนยันในคำฟ้องได้ว่าจำเลยยังคงกระทำความผิดต่อเนื่องออกไป
อีก จึงไม่อาจลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันได้

อนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 82
กำหนดไว้แต่เพียงโทษปรับอย่างเดียวโดยมีอัตราโทษขั้นต่ำที่สูงถึง 100,000 บาท
และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่อาจรอกการกำหนดโทษที่ตามกฎหมาย
มีโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียวได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่หากจำเลยไม่มีเงินพอ
ชำระค่าปรับแล้วต้องถูกกักขังแทนค่าปรับซึ่งในปัจจุบันสภาพสถานที่กักขังยังไม่ต่าง
จากสถานที่จำคุกมากนัก อันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 82 ที่ได้กำหนดโทษปรับไว้เพียงอย่างเดียวก็เพื่อต้องการ

ลงโทษทางทรัพย์สินต่อความผิดในทางการค้าขายในลักษณะนี้มากกว่าต้องการให้
จำเลยต้องถูกคุมขังระยะสั้นเพราะไม่มีเงินพอชำระค่าปรับซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่
ฝ่ายใด ดังนั้น เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 บัญญัติว่า "ผู้ใดต้องโทษปรับ
และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึด
ทรัพย์สิน ใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ" ในคดีนี้หากจำเลยไม่
ชำระค่าปรับก็ไม่ควรกักขังแทนค่าปรับ แต่ให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับแทน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 53วรรคหนึ่ง, 82 ลงโทษปรับจำเลย 100,000 บาท โดยไม่ปรับรายวัน หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับแทน โดยไม่ให้กักขังแทนค่าปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์-พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

แหล่งที่มา ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา